

1503595-42.2021.8.26.0536

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... do acusado Silvio quanto ao crime de tráfico de drogas, e a absolvição da corré Sandra por este delito. Requereu, também, a absolvição de ambos os réus quanto ao crime de associação para o tráfico. Formulou, ainda, pedidos relativos à dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes relativas à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503595-42.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503595-42.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO CARLOS DOMINGUES JÚNIOR e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

SANDRA MARIA MEIRA VIEIRA e SILVIO CARLOS DOMINGUES JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na exordial, o acusado Silvio trazia consigo, para fins de tráfico, 21 porções de cocaína, 21 porções de skunk e 34 pedras de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, finalmente, que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, os acusados Sandra e Silvio tinham em depósito, para fins de tráfico, substâncias que causam dependência física e psíquica, quais sejam, 30 porções de maconha e 37 porções de skunk, que estavam em uma sacola onde também foram encontradas duas balanças de precisão, além de 27 porções de cocaína, 36 porções de maconha e 84 pedras de crack, que estavam em uma bolsa vermelha, onde também foi encontrada a cédula de identidade de Sandra, assim como sete pedras de crack e uma porção de skunk, que estavam em um guarda-roupas, e também 30 porções de maconha que estavam sob o encosto de um sofá, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares. A denúncia foi recebida e os réus foram citados.

Durante a audiência, foi ouvida uma das testemunhas arroladas na denúncia. Foi homologada a desistência quanto à oitiva de uma testemunha policial. Ao final, foram os réus interrogados.

Encerrada a instrução, realizaram-se os debates.

O Ministério Público pediu a procedência parcial da ação, para condenação do acusado Silvio quanto ao crime de tráfico de drogas, e a absolvição da corré Sandra por este delito. Requereu, também, a absolvição de ambos os réus quanto ao crime de associação para o tráfico. Formulou, ainda, pedidos relativos à dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes relativas à calamidade pública e à confissão espontânea, requerendo, ainda, a não aplicação da causa de diminuição de pena constante no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Pediu, por fim, a imposição do regime inicial fechado ao acusado Silvio.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da acusada Sandra por ambos os crimes que lhe foram atribuídos. Quanto ao acusado Silvio, deixou de requerer sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão de sua confissão. Pugnou pela fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pediu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e requereu a fixação do regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelas fotografias de fls. 33/55, pelos laudos periciais, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, porém apenas quanto ao acusado Silvio.

Interrogado em Juízo, o corréu Silvio confessou a prática do tráfico de drogas. Negou ter corrido em posse de uma sacola, alegando que havia acabado de acordar quando policiais entraram na casa e informaram sobre a existência de notícia anônima acerca de tráfico de drogas, com menção ao seu nome. Consignou que a casa era de propriedade da corré Sandra, a quem considera uma tia e que permitiu que lá residisse, e declarou que a acusada Sandra autorizou os policiais a realizarem busca no local. Disse que Sandra, assim como todos os demais moradores da casa, não sabia que estava guardando drogas no imóvel, acreditando que estivesse trabalhando com arte em grafite. Alegou que, durante a pandemia, ficou sem trabalho e sem dinheiro e, conhecendo um indivíduo de nome Anderson, vulgo "Fumaça", envolvido na prática do tráfico de drogas, aceitou a oferta feita por ele para guardar entorpecentes em troca de cem reais. Contou que havia começado a guardar as drogas na quinta-feira antes dos fatos e que as entregaria no sábado, porém acabou sendo detido na sexta-feira e nem mesmo recebeu o dinheiro prometido. Disse que, na quinta-feira à noite, aproveitando a casa vazia, havia ingressado com todos os entorpecentes na casa. Declarou que, na sacola encontrada na fruteira, foram localizadas porções de crack e maconha, além de duas balanças de precisão, sendo que, no sofá-cama do quarto em que dormia, foram encontradas porções de maconha e de cocaína. Disse que também havia porções de skunk no local. Contou que todas as

drogas apreendidas na casa eram de sua responsabilidade e estavam guardadas apenas na cozinha e no quarto em que dormia.

Interrogada em Juízo, a acusada Sandra negou a prática do crime. Disse que o acusado Silvio era amigo de seus filhos e trabalhava com arte em grafite, sendo que, após ele ter perdido a mãe, permitiu que residisse em sua casa. Contou que, na data dos fatos, estava dormindo quando foi chamada e informada por sua filha que a polícia lá estava. Disse que autorizou os policiais a realizarem busca em sua residência, pois desconhecia a existência de drogas no local. Declarou que trabalha como diarista, motivo pelo qual não ficava em sua casa, que era cuidada por suas filhas, e não desconfiava que o acusado lá guardasse entorpecentes. Disse que, ao serem encontradas as drogas pelos policiais, o acusado, inicialmente, negou a prática do crime, mas acabou por admiti-lo em seguida. Contou que não acompanhou a busca realizada pelos policiais no local, pois foi determinado que ficasse em apenas um cômodo com suas filhas. Declarou que também desconhecia a existência das balanças, que foram encontradas sobre um armário. Disse que, na delegacia, soube pelo acusado que ele estava guardando as drogas em sua casa há quatro dias. Contou que na esquina do local onde situa-se sua casa há um ponto de tráfico de drogas e que muitos objetos eram deixados em frente ao seu imóvel e também aos dos vizinhos, o que demandava limpeza diária do local. Consignou que sua casa possui três quartos e o acusado ocupava apenas um deles, sendo que apenas no quarto dele, onde havia um sofá, foram encontrados entorpecentes.

Corroborando a confissão do acusado quanto à prática do crime de tráfico de drogas, a testemunha Rafael Francisco Portella, policial militar à época dos fatos, relatou, sob o crivo do contraditório, que realizava patrulhamento com seu parceiro de farda quando depararam-se com o réu em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas. Disse que o acusado, ao perceber a presença da viatura, correu com uma sacola e entrou em uma casa. Esclareceu que por breve momento perderam o acusado de vista e, ainda ao lado externo da casa, viram um balde com invólucros de cocaína e sacolas com embalagens para drogas. Declarou que, então, ingressaram na casa onde o réu havia entrado momentos antes e o encontraram na cozinha, onde já avistaram quantidade considerável de drogas. Narrou que, nesse momento, a ré Sandra aproximou-se com outras residentes do local e apresentou-se como proprietária da casa, autorizando a realização de busca no imóvel. Disse que ambos os réus declararam ali residir. Relatou que, em quase todos os cômodos da casa, foram encontradas drogas, inclusive dentro de gavetas e guarda-roupas. Esclareceu que, embora o local dos fatos seja conhecido ponto de tráfico de drogas, a casa não era assim identificada. Relatou que os entorpecentes apreendidos dentro do imóvel foram maconha, cocaína e crack, em quantidade razoável, que não soube especificar, tendo sido também apreendidos no local, muitas embalagens para crack, eppendorfs para cocaína e balança de precisão. Narrou que o acusado Silvio, informalmente, assumiu a propriedade da sacola contendo muitas drogas, que havia sido localizada em um recipiente ao lado do fogão, porém negou ser responsável pelos demais entorpecentes encontrados na casa. Disse que a acusada Sandra declarou ser a dona do imóvel e negou o envolvimento com as drogas lá encontradas, sem fornecer esclarecimentos sobre o que foi apreendido. Relatou que houve uma aglomeração de pessoas no local dos fatos e vizinhos pressionaram o réu a assumir a propriedade de todas as drogas encontradas. Não soube dizer se a sacola encontrada na cozinha da casa era a mesma que o réu estava portando quando o viu, pois o perdeu momentaneamente de vista e ele nada estava segurando quando o abordou no interior do imóvel. Consignou que, inicialmente, somente estava com seu parceiro de farda no local dos fatos, havendo na casa somente os demais moradores menores de idade, além dos réus, mas foi solicitado apoio durante as buscas. Não recordou quantos cômodos havia no imóvel onde residiam os acusados e consignou que, no mesmo terreno, havia outra casa, onde residia a filha da acusada Sandra, mas, realizada busca naquele local, nada foi encontrado. Disse que nada foi apurado quanto à prévia associação dos acusados para a prática do tráfico de drogas.

Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado Silvio, quanto ao delito de tráfico de drogas a ele imputado, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra do policial, que de maneira segura descreveu com detalhes

como ocorreu a abordagem do acusado Silvio, bem como de que forma ocorreu a localização e a apreensão das drogas em uma sacola na cozinha onde ele foi abordado, além de esclarecer como se deu a localização das demais drogas e objetos na casa onde ele residia.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Ressalte-se que o depoimento da testemunha Rafael, colhido durante a instrução criminal, mostra-se coerente e harmônico quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização de todos os entorpecentes no imóvel onde o viu ingressar, e encontra-se em verdadeira consonância com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, corroborando a confissão do acusado quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Embora a confissão do acusado Silvio quanto à prática do tráfico de drogas não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelo depoimento da testemunha policial em Juízo, como já destacado.

De outro lado, em que pese a confissão do réu quanto à realização do tráfico, verifica-se que sua alegação de que teria sido abordado pelos policiais já dentro da casa, quando havia acabado de acordar, momento em que foi informado sobre

notícia anônima com menção ao seu nome, não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado.

A fim de que não se alegue, eventualmente, nulidade da prova por “invasão de domicílio” cometida pelos policiais, veja-se que, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, visto que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

É a hipótese do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, de natureza permanente e, portanto, reitera-se, tem sua consumação protraída no tempo. A entrada dos policiais era justificada pela situação de flagrância constatada. Note-se que, no presente caso, havia a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas no local dos fatos. Confira-se:

Como evidenciado pela prova colhida nos autos, a diligência na casa onde foi encontrada grande quantidade de drogas não ocorreu de forma aleatória.

Ao contrário do alegado pelo réu, a testemunha Rafael salientou que o acusado foi visto pela equipe policial ao lado de fora da casa e ele, ao notar a equipe policial, correu em posse de uma sacola, ingressando no imóvel.

Destacou, ainda, a testemunha Rafael que, ao lado externo da casa onde viu o réu entrar, havia um balde contendo materiais relativos ao tráfico de drogas e, diante desse indício, bem como da fuga do réu em posse de uma sacola, ingressou no imóvel com seu parceiro de farda, abordando o acusado Silvio na cozinha.

Asseverou a testemunha Rafael que já na cozinha pode ver considerável quantidade de entorpecentes e, realizada busca na casa com a autorização da corré Sandra, foram encontradas mais drogas e petrechos relacionados ao crime de tráfico de drogas. Outrossim, observe-se que a própria acusada Sandra confirmou ter autorizado a busca em sua residência.

Não se pode alegar, portanto, qualquer tipo de conduta abusiva por parte dos policiais ao entrarem no local, nem que tenham agido de forma aleatória, repita-se. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 603.616/R0, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

Transcreve-se, a seguir, a mencionada tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida – Preliminar – Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO - Presente in casu a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão pelos policiais sem mandado judicial. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. Precedente do STF. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, arma de fogo e

circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2140716-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E LEI N. 10.826/2003, ART. 12, CAPUT) - PRELIMINAR DE NULIDADE - INVASÃO DE DOMÍLIO - Não há nulidade por violação de domicílio quando o policial adentra à casa do acusado, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, por configurada a situação de flagrante (art. 5º, XI, da CF), notadamente em se tratando de crime de natureza permanente. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS AUTOS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria dos delitos. REDUÇÃO DA PENA-BASE - Possibilidade. Dolo normal ao tipo. Penas redimensionadas. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME - Impossibilidade. Deve ser mantido o regime prisional fechado para o crime de reclusão e semiaberto para o apenado com detenção. Tamanha a quantidade de drogas e munições apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - Inviabilidade. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante foi condenado à pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. PREQUESTIONAMENTO - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso da defesa parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1525924-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Insurgência contra suposta violação ilegal de domicílio. Inocorrência. Elementos de prova a indicarem que o ingresso foi escorado em fundadas suspeitas de que lá se praticava crime, com confirmação decorrente da apreensão de considerável quantidade de drogas para o tráfico, segundo confissão. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exacerbado, com fundamentação inidônea. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as reprimendas de PEDRO a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e de ALEXANDRE a 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. " (TJSP; Apelação Criminal 0003609-60.2020.8.26.0302; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 1. PRELIMINAR Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar, que se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente Ademais, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, bem como as autoridades devem assim proceder Não se vislumbra qualquer exceção à atuação de guardas municipais, integrantes dos quadros de força pública no âmbito municipal -Prova ilícita em razão de invasão de domicílio Não cabimento Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza

permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão (...)(TJ-SP - APR: 15014712820208260599 SP 1501471-28.2020.8.26.0599, Relator:Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 21/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:21/06/2021)

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de ilicitude probatória nos procedimentos que cercaram a prisão em flagrante consiste na violação do domicílio sem prévia investigação ou ordem judicial. Liminar deferida. 1. Ilicitude probatória não configurada. Intervenção policial que, a princípio, foi motivada pelo quadro de justa causa. Ação motivada por denúncia anônima que indicou o endereço e a pessoa responsável pelo armazenamento das drogas. Uma vez no local, os policiais avistaram o paciente que ao notar a aproximação da viatura correu para o interior do imóvel que havia sido referido na denúncia. Ilegalidade que não se mostra evidente. Necessidade de aprofundamento da questão ao longo da instrução. 2. Fumus comissi delicti dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Visibilidade e imediatidade da prática delituosa. Quadro de justa causa configurado. 3. Não demonstração do periculum libertatis. Quantidade de drogas pequena. Paciente primário. A ausência de comprovante de ocupação lícita não é, no caso dos autos, elemento suficiente a justificar a imposição da medida extrema. Ausência de elementos indicativos da gravidade concreta. Precedentes. 4. Medida extrema que se apresenta desproporcional. Suficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 22255992520208260000 SP 2225599-25.2020.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 16/10/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2020)

O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça adota esse entendimento, conforme recentes decisões:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protraí-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente. 2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do

contexto fático-probatório. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência". 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína. 5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." (RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGENTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo que se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. III - No caso, ao desobedecer o sinal de parada dado pela Guarda Municipal, o agravante se evadiu e foi perseguido por 15 km até ser interceptado. Admitindo ser foragido da Justiça Pública, o agente, que não portava documentos de identificação, foi conduzido até a sua residência, local onde foram encontrados mais de 9,278 kg de cocaína e tambor contendo lidocaína, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando a dinâmica do flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão, ausência de porte de documento de identificação e reiteração delitiva), bem como o flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do paciente de guardar a droga em sua residência, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial. IV - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que



sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021), é dizer: a desobediência à ordem de parada da autoridade e evasão, por vias públicas, por 15 km até a sua interceptação; a condição de foragido da Justiça Pública sem a devida identificação na abordagem; o cumprimento do dever legal de proteção da autoridade em diligenciar a correta e indispensável identificação do paciente são circunstâncias fáticas sinalizadoras do ingresso regular no domicílio, de onde iniciou a fuga, tanto que encontrada alta quantidade de droga de alto potencial ofensivo. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada a pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

Dessa forma, diante das provas coligidas aos autos, não há qualquer dúvida de que o acusado Silvio residia na casa onde foi encontrada grande quantidade de drogas variadas, nem há dúvidas de que os entorpecentes a ele pertenciam, o que foi por ele mesmo admitido em Juízo, ao declarar que efetivamente guardava drogas em troca de dinheiro.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da variedade e da considerável quantidade de drogas e demais circunstâncias em que estas e os demais petrechos relativos à traficância foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Passo à dosagem da pena.

De outra banda, quanto à acusada Sandra não há nos autos elementos suficientes para embasar sua condenação.

Conforme se verifica da prova colhida em Juízo, a acusada não foi vista pelos policiais em posse de nenhum entorpecente apreendido.

Depreende-se da prova amealhada que, somente após os policiais terem ingressado na casa no encalço do réu e tê-lo abordado na cozinha, a acusada Sandra aproximou-se e identificou-se como proprietária do imóvel, autorizando a busca no local.

Em que pese a testemunha Rafael ter relatado que os entorpecentes foram encontrados em quase todos os cômodos da casa, não soube especificar quantos cômodos haviam nela, nem mesmo foi esclarecido se foram apreendidas drogas ou petrechos relacionados ao tráfico nos quartos utilizados por Sandra e suas filhas.

Da mesma forma, a testemunha Rafael narrou que a ré, já no local dos fatos, declarou desconhecer as drogas encontradas na casa e negou envolvimento com o crime, de forma que apenas a localização de drogas no imóvel a ela pertencente, mas onde apurou-se que um dos quartos era efetivamente ocupado pelo corréu Silvio, que admitiu ser o autor do crime, não é suficiente para demonstrar que a acusada Sandra tivesse participação no delito.

Assim, em relação à corré Sandra, para se lançar uma condenação, é imprescindível a certeza ampla de ser ela coautora do crime ou ter ela concorrido para o crime que lhe foi atribuído. Se houver qualquer dúvida no espírito do julgador, a absolvição é medida que se impõe, porquanto a liberdade de uma pessoa não pode ser coarctada sem que a acusação seja comprovada por provas exatas e seguras.

Frise-se que sua inocência não é patente.

Todavia, diante desse quadro probatório e havendo sérias dúvidas no que pertine à participação no crime descrito na denúncia, a absolvição de Sandra é medida que se impõe, pois antes absolver provável culpado a condenar inocente.

Outrossim, quanto ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06,

não há prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório que possa embasar um decreto condenatório.

Não restou demonstrado que os acusados efetivamente estavam associados entre si, organizando-se previamente para a prática do delito de tráfico de drogas, pois nem mesmo há demonstração suficiente da prática do delito de tráfico de drogas pela acusada Sandra.

Não havendo prova suficiente, portanto, sobre o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, devem ser os acusados absolvidos desta imputação, pois, como se sabe, a dúvida sempre deve ser resolvida em favor dos réus.

Diante do cotejo probatório trazido aos autos, de rigor a condenação do acusado Silvio pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da fundamentação exposta.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de grande disseminador do entorpecente, justifica-se o aumento da pena. Assim, fixo sua pena-base em de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Contudo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ficam as circunstâncias compensadas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida e não é possível reconhecer-se a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade

(567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Outrossim, embora o acusado tenha alegado o início da atividade criminosa no dia anterior à sua prisão, quando guardou na casa todas as drogas que lhe foram entregues por um conhecido envolvido na prática do tráfico de drogas, sua versão não encontrou respaldo nas demais provas colhidas em Juízo.

Ressalte-se que a testemunha Rafael afirmou ter visto o acusado em posse de uma sacola ao lado de fora da casa e ter visto que ele abrigou-se no imóvel ao ver a equipe policial, a indicar que o acusado estava portando drogas fora da casa e não apenas guardando-as no local. Ainda, ressalte-se que a corré Sandra narrou que o próprio acusado Silvio, em solo policial, disse-lhe que ele havia iniciado a prática do crime há quatro dias.

A reunião destes elementos, aliadas à declaração do réu de que não possuía outro trabalho e que apenas estava realizando o tráfico de drogas, além da forma como todos os entorpecentes estavam escondidos na casa, somadas, ainda, à grande quantidade, à natureza e à variedade dos entorpecentes apreendidos, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se a atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, observando que o réu também possuía outros objetos destinados à preparação das drogas, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei) Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1. CONDENAR o réu SILVIO CARLOS DOMINGUES JUNIOR, qualificado nos autos, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita de ter praticado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2. ABSOLVER a ré SANDRA MARIA MEIRA VIEIRA, qualificada nos autos, das imputações que lhe foram feitas, quais sejam, a de ter praticado os delitos previstos no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego ao réu SILVIO o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social.

Destaca-se, ainda, a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o acusado, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra